

Script

Droit matrimonial et successoral

2021

MODULE DROIT MATRIMONIAL ET SUCCESSORAL

CONSEILLER-ÈRE FINANCIER-ÈRE DIPLÔMÉ-E IAF

mendo  formation financière certifiée

Table des matières

1. Le droit matrimonial	3
1.1. Le régime ordinaire de la participation aux acquêts	3
1.2. La communauté des biens.....	8
1.3. La separation des biens.....	10
1.4. Le nouveau droit du divorce	12
2. Le droit des successions.....	15
2.1. Les héritiers légaux.....	15
2.2. La réserve et la quotité disponibles	16
2.3. Exhérédation.....	18
2.4. Procédure en cas de non-respect des réserves	18
2.5. Qu'est-ce qui fait partie de la succession ?	19
2.6. Les dispositions pour cause de mort	20
2.7. Les modes de disposer.....	20
2.8. Le pacte successoral	25
2.9. Réalisation des dernières volontés.....	27
2.10. Le partage de la succession	28
2.11. Mesures en cas de décès.....	30
3. Planification optimale de la succession	31
3.1. Donations et avances sur héritage	31
3.2. Compensation d'héritage.....	32
3.3. Prêt	32
3.4. Donation mixte.....	33
3.5. Usufruit et droit d'habitation	33
3.6. Mesures de protection du conjoint.....	35
3.7. Planification de la succession dans le cas de partenariats assimilables au mariage	36

1. Le droit matrimonial

1. Le droit matrimonial

Le droit matrimonial règle les droits et les obligations réciproques des époux. Ce domaine du droit est traité dans le code civil ( CCS art. 196-251). La loi actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 ; elle a consacré l'égalité entre hommes et femmes.

Les aspects financiers du mariage sont également réglés dans le droit matrimonial, c'est le droit des régimes matrimoniaux qui précise qu'il y a trois régimes de gestion des biens matrimoniaux :

- le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196 et suivants  CCS) ;
- la communauté de biens (art. 221 et suivants  CCS) ;
- la séparation de biens (art. 247 et suivants  CCS).

La situation des biens matrimoniaux peut également être modifiée par d'autres accords contenus dans un contrat de mariage. En plus des régimes indiqués ci-dessus, quelques couples mariés avant 1988 sont encore régis par l'ancien régime de l'union des biens. Les couples qui ont désiré maintenir ce régime dans la nouvelle législation ont dû le demander par écrit sans quoi ils passaient automatiquement dans le régime de la participation aux acquêts.

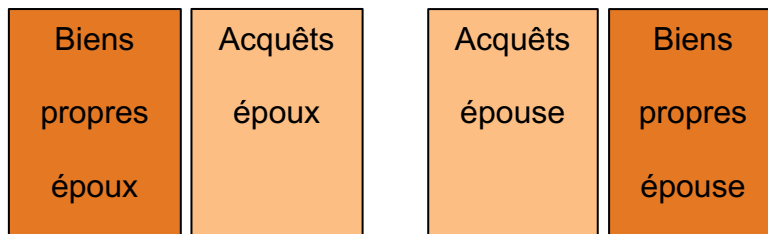
Les pages qui suivent décrivent les différents régimes matrimoniaux. Par ailleurs, les explications sont complétées par des exemples pratiques. La deuxième partie présente également des possibilités de modifications qui peuvent intervenir dans un contrat de mariage ainsi que des communautés de vie qui sont à peine réglées sur le plan du droit. Il est également important d'établir un lien étroit entre le régime matrimonial et le droit des successions qui interviendra lors du décès de l'un des conjoints. C'est la raison pour laquelle la planification financière personnelle comprendra aussi bien le droit des régimes matrimoniaux que celui des successions. Ce n'est que de cette manière qu'il sera possible de trouver des solutions cohérentes et globales.

1.1. Le régime ordinaire de la participation aux acquêts

Ce régime ( CCS 196 ss) intervient automatiquement dans les cas suivants :

- les époux n'ont pas pris d'autres dispositions ;
- les époux se sont mariés avant 1988 et n'ont pas demandé l'ancien régime de l'union des biens ;
- les époux avaient conclu un contrat selon l'ancien droit des régimes matrimoniaux et avaient convenu par écrit vouloir se soumettre au nouveau régime matrimonial à la fin 1988.

Le régime de la participation aux acquêts comprend 4 types de biens différents. Ces définitions de biens sont très importantes lors de la dissolution du mariage par le divorce ou la mort de l'un des conjoints. Ces biens sont les suivants :



1.1.1. Les biens propres

Les biens propres sont constitués de valeurs et d'objets qui appartiennent de par la loi à un conjoint. Ces biens reviendront à ce seul conjoint en cas de dissolution du mariage. En cas de décès, ces biens passeront automatiquement dans la succession du défunt. La loi mentionne les valeurs et les objets qui sont des biens propres. Cette définition stricte a aussi pour conséquence que les biens propres ne peuvent devenir acquêts, même par contrat de mariage.

Les éléments suivants constituent les biens propres ( CCS art. 198) :

- les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel ;
- les biens qui appartiennent à un époux dès le début du régime ;
- les biens qui échoient à un époux par succession ou donation ;
- les créances en réparation d'un tort moral ;
- les biens acquis en remplacement (en réemploi) de biens propres.

Cette liste comprend une répartition de biens qui peut avoir par la suite une grande importance. Lors de la conclusion du mariage, les époux connaissent en général assez bien ce que chacun d'entre eux possède. Les biens qui parviennent aux époux par héritage ou donation ainsi que les biens acquis en remplacement jouent un rôle plus important. Un héritage ou une donation peuvent modifier considérablement le ménage des époux. L'exemple qui suit vous permettra de mieux comprendre cette situation :

Monsieur X reçoit CHF 500'000.– en héritage. Les époux X qui vivent aujourd'hui dans un petit appartement en location avec leur fils conviennent d'acheter une maison avec cet héritage. Après quelques années, la vie du couple est tellement perturbée qu'une procédure de divorce est inévitable. Le problème de madame X se trouve maintenant dans le fait que toute la maison appartient à monsieur X. Elle doit donc quitter la maison et renoncer au standard de vie qu'elle connaissait.

Les biens acquis en remplacement et les augmentations de valeurs des biens propres peuvent également avoir une grande importance. Il y a bien acquis en remplacement lorsqu'un époux vend un bien (p. ex. un immeuble ou des titres) et achète un autre bien avec le produit de la vente.

Ce nouvel achat demeure un bien propre, également lorsque l'investissement s'effectue dans un autre type de bien (p. ex. vente d'actions pour acheter un immeuble.) Des exemples traitant de ces deux points particulièrement importants sont présentés après la définition des acquêts.

Chaque époux peut demander à son conjoint un inventaire de ses biens. L'exactitude de cet inventaire est incontestable lorsqu'il a été dressé par un notaire dans l'année où les biens ont été acquis. En cas de contestation, l'époux doit prouver qu'un bien lui appartient en propre sans quoi il est propriété des deux époux.

1.1.2. Les acquêts

Les biens suivants font partie des acquêts :

- le produit du travail (salaire, primes, etc.) ;
- les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ;
- les revenus des biens propres.

Cette liste n'est pas exhaustive. En principe tous les flux financiers intervenus pendant la durée du mariage entrent dans les acquêts. La plupart de ces biens ne posent pas de problème. Les revenus des biens propres présentent parfois quelques difficultés. On entend par revenus les intérêts, les dividendes, les prestations périodiques (rentes), etc. Ne font pas partie de cette catégorie les gains en capital, par exemple ceux qui ont été obtenus par des actions. Les dividendes font certainement partie des acquêts mais les gains en capital augmentent les biens propres.

La différenciation des biens entre biens propres et acquêts est souvent difficile en pratique car cette séparation n'intervient que dans le cas d'un divorce ou d'un décès après des années ou même des dizaines d'années de vie commune. L'exemple suivant permet d'illustrer ce problème :

Lors de la conclusion du mariage, madame X disposait de CHF 100'000.—, monsieur X de CHF 50'000.—. Alors que monsieur X consacra la majeure partie de son bien propre à ses loisirs et disposait d'un compte d'épargne auprès de sa banque, madame X a géré un portefeuille d'actions. Au cours des 10 dernières années, madame X a procédé à différents investissements et à des modifications de son portefeuille. Elle a par ailleurs pu épargner mensuellement CHF 1'000.— de son salaire. Elle a également investi cet argent en actions. Après de bonnes années boursières, madame X dispose aujourd'hui d'un portefeuille de près de CHF 500'000.—. Lorsque monsieur X demande le divorce, un différend éclate au sujet du portefeuille d'actions car il se pose la question de savoir quelle part est constituée d'un bien propre et quelle part est constituée d'acquêts. Les intérêts et les dividendes ainsi que l'épargne mensuelle investie constituent des acquêts. Mais les CHF 100'000.— du début du mariage et les gains en capital (également ceux qui proviennent du emploi) sont des biens propres.

Chaque époux gère, utilise et dispose de ses acquêts et de ses biens propres.

1.1.3. Dissolution du mariage en cas de décès

Lors du décès de l'un des conjoints, il y a tout d'abord une liquidation du régime matrimonial, on commence par répartir les biens selon le droit matrimonial. Il y a tout d'abord une moitié des acquêts qui passe au conjoint survivant et l'autre moitié passe dans la succession. Les biens propres du défunt passent également dans la succession.

Ce ne sont pas les acquêts individuels qui sont déterminants mais bien l'ensemble des acquêts des époux. L'exemple suivant permet de mieux comprendre cette répartition des biens :

L'époux a économisé mensuellement CHF 1 500.— sur son salaire à l'aide d'un fonds d'épargne. Ses acquêts s'élèvent à CHF 350'000.—. L'épouse qui travaille à temps partiel n'a pas pu épargner pendant la durée du mariage. Les deux ont apporté CHF 50'000.— (biens propres). Après la dissolution des acquêts CHF 175'000.— passent en cas de décès de l'époux à l'épouse (1/2 des acquêts). Les autres CHF 175'000.— et les biens propres de l'époux de CHF 50'000.— passent à la succession.

Une dette du conjoint sur les acquêts n'est pas prise en considération. Le conjoint survivant n'est ainsi pas responsable des dettes du conjoint décédé. Lorsque un des époux entreprend des investissements qui sont financés avec des fonds de l'autre époux et qu'il y a une plus-value (p. ex. des investissements dans l'immobilier), l'autre époux participe alors automatiquement à la plus-value. La part de plus-value de l'autre époux est calculée de la manière suivante :

Exemple :

Dans le cas d'un investissement immobilier, une épouse a prêté CHF 50'000.– à son époux. Lors de l'achat, l'immeuble a coûté CHF 300'000.–. Au décès, l'immeuble est évalué après impôt à CHF 450'000.–. L'épouse ne dispose pas seulement des CHF 50'000.– qu'elle a prêtés, mais de CHF 75'000.–.

Formule pour le calcul de la part de plus-value :

$$\frac{\text{Capital investi CHF 50'000} * \text{plus-value de CHF 150'000}}{\text{Somme totale investie CHF 300'000}} = \text{CHF 25'000}$$

La part de plus-value peut être modifiée ou exclue par un accord écrit. La répartition des acquêts peut être modifiée par un contrat de mariage. Des informations sont données au chapitre «Le contrat de mariage». Vous trouvez dans la suite un exemple de décomptes pour la dissolution de l'union conjugale dans le cas de la participation aux acquêts.

1. Patrimoine conjugal net le jour du décès	1'000'000
./. Biens propres de l'épouse	-150'000
Apport au début du mariage	50'000
Héritage du père	100'000
./. Biens propres de l'époux	- 170'000
Apport au début du mariage	150'000
Donation de la soeur	20'000
= Solde des deux époux	680'000
Part matrimoniale de l'épouse	490'000
Biens propres	150'000
½ du solde	340'000
Part matrimoniale de l'époux	510'000
Biens propres	170'000
½ du solde	340'000

Pour déterminer le patrimoine conjugal, il est important de savoir comment les valeurs du patrimoine sont estimées au jour du décès :

Titres, comptes et autres avoirs	Soldes / cours du jours
Objets de valeur (bijoux, tableaux etc.)	Valeur commerciale
Immeubles	Valeur vénale ./ . hypothèques
Assurances	Valeur de rachat

En plus de la dissolution du régime matrimonial calculée selon les éléments donnés ci-dessus, le conjoint survivant peut aussi demander :

- l'usufruit ou le droit d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal ;
- l'attribution du mobilier de ménage en propriété ;
- la propriété de la maison ou de l'appartement conjugal à décompter sur les droits des héritiers.

1.1.4. Liquidation du régime matrimonial par le divorce

Les mêmes répartitions que celles expliquées ci-dessus interviennent lorsque le mariage est dissous par le divorce. On sépare également les biens propres des acquêts. Chaque époux conserve ses biens propres et dispose d'un droit de 50% sur les acquêts.

Des facteurs supplémentaires interviennent toutefois dans le divorce. Ainsi, dans le nouveau droit du divorce, chaque conjoint a droit à la moitié du capital de libre passage de l'autre. Ce droit s'exerce sur le capital de libre passage épargné pendant la durée du mariage, sans tenir compte du fait que ce capital soit géré par une caisse de pensions ou se trouve sur un compte de libre passage. D'autres prétentions peuvent également intervenir selon les situations, par exemple des contributions d'entretien.

1.2. La communauté des biens

Le régime de la communauté des biens résulte d'un contrat de mariage. Dans le régime de la communauté, les biens du mari et ceux de la femme sont réunis en un tout qui appartient indivisément aux deux époux. On distingue les trois masses suivantes :

- Les biens propres de la femme
- Les biens propres du mari
- Les biens communs

1.2.1. Les biens propres

Les biens propres de chaque époux comprennent les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral (p.ex. pour lésions corporelles). Les biens propres sont donc notablement moins nombreux que dans le régime de la participation aux acquêts.



1.2.2. Les biens communs

Les biens communs comprennent tous les biens (y compris les apports) et les revenus des époux. Tout bien est présumé commun s'il n'est pas prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.

1.2.3. Propriété

Les biens propres sont la propriété exclusive de chaque conjoint, alors que les biens communs appartiennent indivisément aux deux époux.

1.2.4. Administration

Les époux gèrent et disposent ensemble des biens communs. Chacun d'eux est maître de ses biens propres. Lorsqu'un des époux exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise au moyen des biens communs, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l'exercice de ces activités.

1.2.5. Responsabilité

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs des dettes qu'il a contractées et qui présentent un lien objectif avec les biens communs, telles que les dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise.

De ce fait chacun des époux supporte le risque professionnel et commercial encouru par l'autre, raison pour laquelle le régime de la communauté des biens n'est pas recommandé lorsque l'un des époux s'expose à des risques dans ses activités professionnelles ou dans les investissements qu'il effectue.

En revanche, chacun des époux répond seul des dettes qui ne grèvent que ses biens propres, qui résultent d'un acte illicite ou qu'il a apportées dans le mariage.

1.2.6. Divorce

En cas de divorce, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux, à moins qu'un contrat de mariage n'en dispose autrement.

1.2.7. Décès

En cas de décès de l'un des époux, les biens de la communauté sont partagés par moitié entre le conjoint survivant et les héritiers du défunt (parmi lesquels figure également le conjoint survivant). Il y a donc un partage par moitié dans tous les cas, même si l'un des époux a apporté dans le mariage la quasi-totalité des biens communs ou acquis ceux-ci par son travail pendant la durée du mariage.

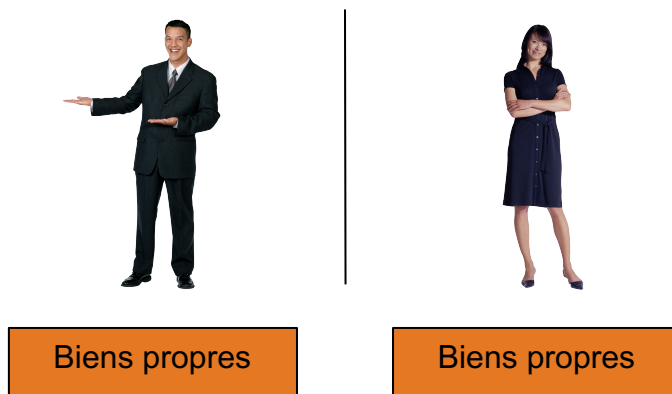
Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié. Toutefois, une telle convention ne saurait porter atteinte à la réserve des descendants.

1.2.8. Part à la plus-value

Les dispositions relatives à la plus-value s'appliquent dans la communauté des biens de la même manière que dans le régime de la participation aux acquêts.

1.3. La séparation des biens

Le régime de la séparation des biens résulte également d'un contrat de mariage.



1.3.1. Les biens matrimoniaux

Dans le régime de la séparation des biens, les rapports patrimoniaux entre les époux sont très simples. Chacun d'eux conserve la propriété des biens qu'il apporte dans le mariage. De ce fait, ce régime ne connaît que deux masses de biens :

- les biens propres de la femme
- les biens propres du mari

1.3.2. Administration

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens et des revenus de son travail.

1.3.3. Responsabilité

Comme il n'y a pas de biens matrimoniaux, chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. Il n'encourt aucune responsabilité pour les dettes de son conjoint.

1.3.4. Décès

Il n'y a pas de liquidation du régime matrimonial. Le conjoint survivant conserve ses biens. Quant aux biens du défunt, ils constituent sa succession, à laquelle le conjoint survivant est intéressé en qualité d'héritier. Dans la séparation de biens, le conjoint survivant n'a pas droit à une part résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il n'a donc aucun droit sur les revenus du travail du défunt, même si, par son activité (par exemple l'éducation des enfants), il a contribué à la réussite professionnelle de son conjoint.

1.3.5. Naissance

La séparation des biens résulte

- d'un contrat de mariage
- de la loi
 - lorsqu'un époux qui vit sous le régime de la communauté des biens est mis en faillite
 - en cas de séparation de corps
- d'une ordonnance du juge
 - à la demande d'un époux :
 - ☐ lorsque l'autre époux est surendetté ou que sa part des biens communs est saisie
 - ☐ lorsque l'autre époux compromet les intérêts du requérant ou de la communauté
 - ☐ lorsque l'autre époux refuse sans raison valable de donner son accord à un acte de disposition concernant les biens communs
 - ☐ lorsque l'autre époux refuse d'informer le requérant sur ses revenus, sa fortune, ses dettes ou sur les biens communs
 - ☐ lorsque l'autre époux est durablement incapable de discernement

- à la demande de l'autorité de surveillance en matière de poursuites
 - ☐ lorsque l'un des époux vivant sous le régime de la communauté des biens est poursuivi pour ses propres dettes et que sa part des biens communs a été saisie
 - ☐ à la demande du représentant legal d'un époux durablement incapable de discernement.

1.4. Le nouveau droit du divorce

Un divorce exerce une grande influence sur la situation financière d'une personne. En plus des charges personnelles et psychologiques, les modifications financières exercent certainement une incidence considérable sur les intéressés. Les conseillers financiers doivent tenir compte de la possibilité d'un divorce dans leurs réflexions. On compte qu'en Suisse 50% des mariages se terminent par un divorce.

Un nouveau droit du divorce est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Des modifications importantes sont intervenues pour toutes les personnes concernées. Il s'agit en particulier des points suivants :

- possibilité d'un divorce par consentement mutuel (le problème de la «faute» est éliminé) ;
- égalité entre les sexes ;
- amélioration de la situation juridique des enfants.

Selon le nouveau droit, les possibilités suivantes se trouvent à la disposition des couples qui désirent divorcer (il est toutefois indispensable de passer par un tribunal) :

- divorce par consentement mutuel (un accord préalable est nécessaire = procédure simplifiée devant le tribunal) ;
- divorce fondé sur la plainte d'un des époux après 2 années de séparation ou lorsque la poursuite du mariage n'est plus envisageable.

Le nouveau droit du divorce prend mieux en compte les intérêts des enfants dans tout le processus. Les enfants peuvent être entendus, c'est une nouveauté. Les enfants peuvent faire part de leurs souhaits au tribunal ou à un tiers, à moins que cela ne soit pas possible pour des raisons d'âge. Il est même possible aux enfants de faire représenter leurs intérêts à un éventuel procès.

C'est l'autorité de tutelle qui interviendra pour représenter les enfants. Il faut réunir trois conditions pour que les époux en instance de divorce puissent reprendre l'autorité parentale commune :

- les deux époux doivent déposer une demande commune ;
- il doit y avoir un accord écrit des parents, approuvé par le tribunal (convention de divorce), sur l'éducation des enfants et la répartition des frais d'entretien ;
- l'autorité parentale commune doit être compatible avec le bien-être de l'enfant.

1.4.1. Conséquences sur la prévoyance professionnelle

Le nouveau droit du divorce comprend automatiquement une égalisation des prestations futures de la prévoyance professionnelle. Indépendamment du régime matrimonial et de l'éventuel contrat de mariage, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de libre passage de l'autre conjoint pour la durée du mariage. Dans le cas où les deux conjoints disposent d'un avoir auprès d'une institution de prévoyance, c'est la différence qui fait l'objet d'une égalisation. Depuis le 1er janvier 2017, c'est le jour de l'introduction de la procédure de divorce qui fait foi et plus la date du divorce (art. 22a)

Contrairement à cette répartition des droits dans le 2e pilier, les avoirs du pilier 3a sont égalisés sur le plan du régime matrimonial. Cela peut provoquer des conflits en fonction du régime et des accords matrimoniaux. Il peut en particulier exister une situation difficile si un indépendant assure sa prévoyance professionnelle uniquement par le (grand) pilier 3a.

Lorsqu'un époux a déjà bénéficié par le passé d'une prestation de libre passage, il n'est plus possible de recommencer cette opération. Dans ces cas, une compensation est accordée sous la forme d'un dédommagement en capital ou sous la forme d'une rente. Il est possible de renoncer à l'égalisation de la prévoyance professionnelle dans le cas où la prévoyance vieillesse et invalidité est réglée d'une autre manière.

Le «transfert» d'une partie de la prestation de libre passage à l'époux divorcé a pour conséquence des prestations réduites pour celui qui paie le libre passage. L'institution de prévoyance doit de ce fait offrir la possibilité à l'assuré de racheter la part manquante. Ces rachats sont déductibles du revenu fiscal.

1.4.2. Contributions d'entretien

Les contributions d'entretien constituent en cas de divorce un élément de conflit financier. Le principe est que le nourricier continue d'assumer ses obligations. Les époux ne contestent en général pas qu'une contribution d'entretien est nécessaire pour les enfants. La détermination d'une contribution d'entretien à l'ancien époux est source de désaccords. Il y aura rarement une contribution d'entretien si les deux époux exercent une activité professionnelle.

Cependant, la contribution d'entretien sera sensiblement plus élevée si un des époux a assumé le ménage et l'éducation des enfants pendant une longue période. Un époux qui a assumé le ménage et l'éducation des enfants ne peut pas être forcé à reprendre une activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- la personne en instance de divorce a dépassé l'âge de 45 ans ;
- le mariage a duré au moins 10 ans.

Dans le cas d'un divorce sans accord à l'amiable, l'ensemble des revenus du couple est additionné par le tribunal. Le minimum vital est calculé pour les deux époux et le revenu est réparti de manière adéquate. Le solde est réparti pour moitié aux époux. On en arrive ainsi à une solution 50/50.

Exemple :

les époux Durand ne peuvent pas se mettre d'accord sur les conditions financières de leur divorce. Monsieur Durand, 50 ans, dispose d'un revenu annuel net de CHF 122'000.—. Madame Durand, 49 ans, n'est plus active sur le plan professionnel depuis 24 ans. Elle a élevé trois enfants, dont deux demeurent encore à la maison.

Le juge décide que Madame Durand ne doit pas reprendre une activité salariée. Une contribution d'entretien de CHF 24'000.— est fixée pour les enfants. Monsieur Durand doit verser CHF 48'000.— à son ex-épouse à titre de contribution d'entretien sur le solde du revenu. Il reste donc à Monsieur Durand un revenu de CHF 50'000.—.

L'exemple démontre que le changement de la situation financière peut être brutal. Monsieur Durand ne doit financer que ses propres dépenses mais les coûts totaux de la famille sont plus élevés que précédemment. Les dépenses de logement augmentent car Monsieur Durand doit louer son propre logement ou s'acheter sa propre maison.

2. Le droit des successions

2. Le droit des successions

Le droit des successions est réglé dans le code civil suisse (CCS) à partir de l'art. 457. Le droit des successions règle la répartition du patrimoine d'une personne décédée. La loi traite clairement de la plupart des problèmes mais il reste de la place pour des solutions individuelles.

Il est certainement avantageux pour une personne disposant d'un certain patrimoine de planifier sa succession déjà au moment de son vivant afin de prévoir une situation claire en cas de décès ; cela est d'autant plus le cas pour un propriétaire d'immeubles ou d'entreprises. Ces deux types de patrimoines sont en général difficilement liquidables et cela peut provoquer des difficultés insurmontables. Pour les propriétaires d'entreprises, il arrive en plus qu'une société doive être dissoute afin de pouvoir payer les héritiers. Cette situation est particulièrement préjudiciable lorsque d'autres sociétaires (p. ex. dans le cas d'une société en nom collectif) ou des collaborateurs sont touchés par ces mesures.

2.1. Les héritiers légaux

Les héritiers légaux sont concernés lorsque le défunt n'a pas pris de dispositions lors de son vivant, par exemple dans un testament. Les héritiers légaux comprennent uniquement des parents par le sang comme les descendants, les parents, les frères et soeurs, etc. Le conjoint marié constitue l'exception, c'est la seule personne non parente par le sang qui fasse partie des héritiers légaux qui sont donc les suivants :

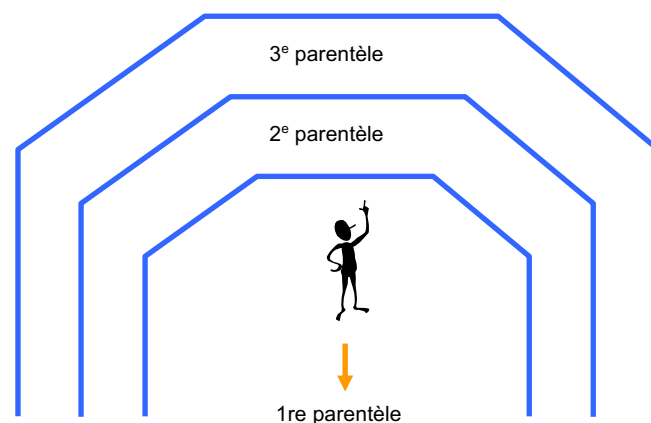
1re parentèle :	les premiers héritiers d'un défunt sont ses descendants. Si ceux-ci sont déjà décédés, leurs droits passent à la succession. Cette catégorie de descendants est traitée de la même manière et hérite dans les mêmes proportions.
2e parentèle :	les parents du défunt constituent le second groupe des héritiers légaux. Dans le cas où le défunt ne laisse pas de descendants, la succession passe aux parents. Le père et la mère héritent dans ce cas dans les mêmes proportions. Dans le cas où les parents ou l'un d'entre eux sont déjà décédés, la succession passe à leurs descendants dans les mêmes parts. Ce sont alors les frères et soeurs du défunt.
3e parentèle :	lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni ascendants, la succession passe aux grands-parents. Si ceux-ci sont décédés, la part échoit aux héritiers de la même ligne (oncles/tantes). La troisième parentèle est la dernière des héritiers légaux. D'autres parents (arrière grands parents) ne sont plus considérés.

Lorsque le défunt laisse un conjoint, cette personne hérite en concours avec les parents désignés ci-dessus :

- de la moitié de la succession, en concours avec les descendants ;
- des trois-quarts de la succession, en concours avec le père, la mère ou leur postérité ;
- de la succession entière à défaut du père, de la mère ou de leur postérité.

A défaut d'héritiers et de testament, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton. Ce dernier doit toutefois procéder à plusieurs reprises à un appel aux héritiers avant de reprendre la succession.

Le graphique qui suit permettra de mieux comprendre le système des parentèles :



2.2. La réserve et la quotité disponibles

Plusieurs héritiers légaux ainsi que le conjoint sont protégés par la loi contre l'éventuel arbitraire du testateur par des réserves. Cela a pour conséquence que le testateur ne peut pas entièrement transmettre son héritage à des tiers car la loi prévoit qu'une partie de l'héritage, appelée réserve, passe obligatoirement aux héritiers légaux.

La réserve est donc constituée de fractions de l'héritage dont le testateur ne peut pas disposer librement. Dans le cas où le testateur ne respecterait pas ces règles dans un testament ou une assurance-vie, les héritiers qui sont lésés dans leurs parts peuvent se plaindre devant un tribunal (action en réduction). La plainte doit être acceptée par le juge et les dispositions du testament doivent être modifiées en fonction des dispositions légales.

La réserve est la suivante (calculé sur la totalité de la succession) :

	Part réservataire
descendant avec un conjoint survivant :	3/8 de la succession
descendant sans conjoint survivant :	3/4 de la succession
conjoint survivant avec descendant :	1/4 de la succession
conjoint survivant sans descendant avec les parents du défunt :	3/8 de la succession
conjoint survivant sans descendant, sans les parents du défunt :	1/2 de la succession
parents du défunt avec le conjoint survivant :	1/8 de la succession
parents du défunt sans conjoint survivant :	1/2 de la succession

Les autres héritiers légaux (frères et soeurs, grands-parents, etc.) ne bénéficient plus de réserves.

Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une réserve fait partie de la quotité disponible dont le testateur peut disposer librement, voici un exemple :

Monsieur X laisse une épouse ainsi que deux enfants. La succession s'élève à CHF 200'000.—. De son vivant, monsieur X avait l'intention de laisser une plus grande partie de son héritage à un neveu qui devait prendre sa succession dans son commerce. Quel est le montant de la quotité disponible ?

Les héritiers légaux, la réserve et la quotité disponible se présentent ainsi :

Parent	Parts d'héritage	Réserve	Quotité disponible
Conjointe	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	
Enfant 1	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	
Enfant 2	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	
Total	1	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$

Monsieur X peut donc disposer librement des $\frac{3}{8}$ de sa succession.

Voici un résumé des réserves et des quotités disponibles :

Le testateur laisse	Parts d'héritage	Réserve	Quotité disponible
Conjoint	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Conjoint et descendants	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$
Conjoint et parents	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Conjoints et sœurs/frères	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$
Descendants	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
Parents en tant qu'héritier unique	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Parents et sœurs/frères	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
Sœurs/frères	1	0	1
Grand-parents et leurs descendants	1	0	1

2.3. Exhérédation

Une exhérédation intervient lorsque le testateur ne désire pas léguer ses biens. Il ne s'agit pas de modifier la quotité disponible mais de ne pas transmettre de biens à un héritier légal. Mais cela n'est possible que si un héritier réservataire a commis un délit grave contre le défunt ou l'un de ses proches. C'est également le cas lorsque cet héritier a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. L'exhérédation doit être clairement indiquée comme telle. Par ailleurs, le testateur doit indiquer le motif de l'exhérédation.

2.4. Procédure en cas de non-respect des réserves

Un héritier qui ne se sent pas correctement traité doit tout d'abord déterminer à quelle part il a droit du point de vue de la loi. Il s'agit de déterminer sur la base de son lien de parenté avec le défunt si sa part fait partie de la réserve. Si c'est le cas, il faut ensuite déterminer la part de réserve en fonction des parentèles.

L'héritier qui constate qu'il a été lésé dans sa part de réserve peut intenté une action en justice. Dans ce cas, il ne suffit pas d'annoncer cette lésion lors du partage de la succession à la personne qui en est responsable. Il est dans ce cas indispensable de s'adresser au juge.

Exemple :

Le défunt X laisse une succession de CHF 200'000.–. Il octroie CHF 20'000.– à chacun de ses enfants ainsi que CHF 60'000.– à son épouse ainsi que le solde de CHF 120'000.– à un ami.

Les enfants se sentent lésés en tant qu'héritiers réservataires et intentent une action en justice. Le juge leur donne raison car leur réserve s'élève pour chacun à 3/16, donc CHF 37 500.–, soit au total CHF 75'000.–. La répartition des parts s'effectue de la manière suivante après le jugement :

Total de la succession	CHF 200'000
Réserve descendants	CHF 75'000
Réserve épouse	CHF 50'000
Quotité disponible	CHF 75'000
Dont à l'épouse	CHF 10'000
Dont à l'ami	CHF 65'000

L'ami devra donc déduire CHF 55'000.– destinés aux descendants sur les CHF 120'000.– initialement prévus.

2.5. Qu'est-ce qui fait partie de la succession ?

Tout le patrimoine du défunt passe dans la succession après la liquidation du régime matrimonial. Il faut toutefois tenir compte de quelques particularités :

- le capital décès d'une assurance risque pur est directement transmis au bénéficiaire et ne joue aucun rôle dans la répartition de la succession car cette opération ne concerne pas le patrimoine du défunt. En effet, les primes payées ont été uniquement consacrées à une protection contre un risque et représentent des frais d'entretien ;
- le capital décès versé par une assurance mixte est également directement remis au bénéficiaire. Toutefois, la valeur de rachat calculée au moment du décès est comptée dans la succession car elle exerce une influence sur les réserves. Des héritiers réservataires peuvent faire valoir leurs droits auprès des bénéficiaires dans le cas où ils auraient été lésés dans leurs droits. C'est la valeur de rachat du capital qui est déterminante et pas la prestation d'assurance octroyée ;
- les rentes et prestations en capital du deuxième pilier ne concernent pas le droit de la succession et ne tombent pas dans la succession. Il existe un droit légal aux prestations des descendants selon la loi sur le 2e pilier ;
- dans le cas de prestations du pilier 3a, il faut à nouveau déterminer l'existence d'une valeur de rachat. Les prestations de prévoyance d'un organisme bancaire font partie de la succession.

2.6. Les dispositions pour cause de mort

Dans le cadre de ses possibilités, un testateur peut disposer librement de la quotité disponible de son héritage pour exercer son choix de manière individuelle. Il peut utiliser les possibilités suivantes :

- l'institution d'héritiers (y compris héritier grevé et appelé) ;
- le legs ;
- les règles de partage ;
- l'exécuteur testamentaire ;
- la fondation.

Ces mesures doivent se trouver dans un document pour qu'elles puissent être appliquées lors du partage de la succession :

- le testament ou
- le pacte successoral.

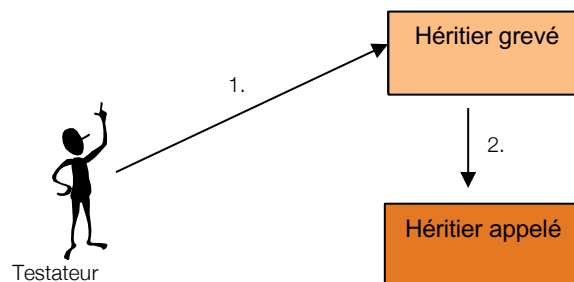
2.7. Les modes de disposer

2.7.1. L'institution d'héritier

Le testateur peut instituer d'autres héritiers à côté des héritiers légaux. Mais il est important de ne pas léser les héritiers réservataires. Les héritiers doivent être clairement définis en indiquant le nom, le prénom ainsi que le domicile (ou même le lieu d'origine) et la date de naissance de l'héritier.

2.7.2. Héritier grevé /Héritier appelé

En plus de l'institution « normale » d'héritier, le testateur peut également disposer de la transmission ultérieure de sa succession. Cela est concrétisé par l'institution d'un héritier grevé et d'un héritier appelé. Le testateur indique non seulement qui doit hériter d'une part de ses biens après sa mort mais également qui héritera de cette part après la mort du premier héritier.



Le testateur ne peut bien entendu disposer que des biens qu'il lègue à l'héritier grevé. L'héritier grevé ne peut de son côté disposer librement des biens dont il hérite, car cet héritage devra être restitué après sa mort à l'héritier appelé (CCS Art. 491). L'héritier grevé ne peut non plus donner le bien qu'il reçoit ou le léguer à une autre personne que l'héritier appelé ; l'héritier grevé ne peut donc disposer de ce bien que d'une manière limitée.

Du point de vue fiscal, c'est le rapport de parenté entre le testateur et l'héritier grevé qui est décisif ; il en va de même de l'héritier appelé pour le second héritage. Le lien de parenté entre l'héritier grevé et l'héritier appelé ne joue donc aucun rôle. La partie « impôts » donne des renseignements complémentaires sur les droits de succession.

Exemple :

Monsieur X, veuf, sans descendants, lègue une maison de vacances dans le canton du Valais à sa soeur Y. Monsieur X institue déjà son neveu W comme héritier appelé, il est le fils du frère de son épouse décédée. La soeur Y utilise la maison jusqu'à sa mort. Ce bien passe ensuite au neveu W alors que les autres biens passent à la succession de la soeur Y.

2.7.3. Legs

Un testateur peut aussi désirer qu'une personne ou une institution en dehors de la parenté reçoive un objet ou un montant en espèces. Cela peut être réalisé sous la forme d'un legs. On désigne en règle générale un objet déterminé (p. ex. l'équipement de plongée du testateur) ou un montant déterminé (p. ex. CHF 20'000.-). On peut également définir un certain pourcentage de la succession.

Exemple :

Monsieur X lègue 5% de sa succession à la Croix Rouge suisse.

Ces indications de pourcentages ne sont pas toujours favorables car elles ne correspondent pas toujours à ce que le testateur voulait léguer au moment de l'établissement du contrat. Entre temps, des gains en capitaux ont fait fortement augmenter le patrimoine du testateur et le montant du legs devient plus élevé.

Les héritiers sont responsables du transfert du legs. Un exécuteur testamentaire est souvent prévu, il effectue alors le transfert au nom des héritiers. Dans le cas où des dettes existent en relation avec un legs (p. ex. dans le cas d'immeubles), il faut alors explicitement mentionner que les dettes doivent être reprises en même temps que le legs.

2.7.4. Règles de partage

Le partage d'une succession constitue souvent une tâche difficile. On peut en arriver à des situations assez embrouillées. Les problèmes seront souvent programmés d'avance lorsque la succession se compose d'un ou de plusieurs immeubles ou d'une société. Les héritiers devront alors compenser entre eux les biens dont ils héritent ce qui entraîne souvent des difficultés.

Il peut aussi arriver que les héritiers ne soient pas d'accord sur la manière dont ils reprendront les biens. L'exemple qui suit permettra de mieux comprendre le problème :

Les trois héritiers de monsieur X doivent partager la succession qui se compose des biens suivants :

Immeuble (après déduction de l'hypothèque)	CHF 700'000
Part d' une société en nom collectif	CHF 150'000
Papiers valeurs et comptes	CHF 50'000
Total de la succession	CHF 900'000
Part par héritier 1/3	CHF 300'000

On en vient à un conflit généralisé car les héritiers ne peuvent pas se mettre d'accord sur les biens à reprendre et en particulier la manière de dédommager les autres héritiers pour celui qui reprend l'immeuble.

Pour éviter ces disputes, le testateur peut déjà régler la reprise de l'entreprise de son vivant et prescrire des règles de partage dans ses dispositions pour cause de mort. Mais il est, comme toujours, important de ne pas léser les réserves. L'exemple précédent pourrait devenir ce qui suit après utilisation des règles de partage :

Monsieur X a disposé que tous les enfants doivent hériter de parts identiques. L'enfant 2 reprend les parts de la société en nom collectif (cela a déjà été discuté avec les autres associés) et l'enfant 1 reprend l'immeuble. La compensation est effectuée par l'enfant 1 qui paie les deux autres enfants. Il se procure les liquidités par une augmentation de l'hypothèque. Le partage de l'héritage se présente alors de la manière suivante :

Total de la succession	CHF 900'000
Part de chaque héritier 1/3	CHF 300'000
L'enfant 1 reprend l'immeuble	CHF 700'000
L'enfant 1 paie aux autres héritiers (augmentation de l'hypothèque)	- CHF 400'000
Total enfant 1	CHF 300'000
L'enfant 2 reprend la part de société en nom collectif	CHF 150'000
L'enfant 2 reprend les autres biens	CHF 50'000
L'enfant 2 reprend la part de compensation de l'enfant 1	CHF 100'000
Total enfant 2	CHF 300'000
L'enfant 3 reprend la part de compensation de l'enfant 1	CHF 300'000
Total enfant 3	CHF 300'000

2.7.5. Exécuteur testamentaire

Le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire dans ses dispositions pour cause de mort. On désigne en général une personne de confiance dans l'environnement privé du testateur ou un professionnel de la matière (notaire, conseiller financier, etc.). L'exécuteur testamentaire s'occupe des travaux administratifs sur mandat du testateur : relations avec les administrations fiscales, les inventaires, l'administration du patrimoine et il applique les dispositions du testament. Cette tâche est assez étendue lorsque le patrimoine se compose de plusieurs éléments et qu'il y a beaucoup d'héritiers.

L'exécuteur testamentaire est responsable vis à vis des héritiers et il doit leur fournir les renseignements voulus. Son mandat consiste à appliquer les dernières volontés du testateur et il dispose à cet effet des pouvoirs nécessaires. Il ne peut agir sans l'accord des héritiers. Il peut également intervenir en tant que médiateur en cas de désaccord entre les héritiers. Il est toujours avantageux de faire intervenir un exécuteur testamentaire lorsque le patrimoine et les vœux des héritiers se trouvent dans une situation complexe. Comme l'exécuteur testamentaire exerce une responsabilité importante, il est recommandé de confier cette tâche à un professionnel dans les cas complexes.

L'exécuteur testamentaire demandera un dédommagement pour son travail mais on ne confiera pas cette tâche difficile à une personne qui sera dépassée. La rémunération est définie sur la base d'un salaire horaire (honoraire ; selon décision du tribunal fédéral).

L'exécuteur testamentaire peut être une personne physique ou morale. La nomination de l'exécuteur testamentaire s'effectue par l'autorité qui a ouvert le testament. L'exécuteur testamentaire peut refuser le mandat dans les 14 jours – le silence vaut acceptation.

2.7.6. Fondation

Le testateur peut disposer qu'une partie de sa succession revienne à une fondation ou que celle-ci reçoive un legs. Il peut également créer lui-même une fondation qui poursuit un but d'intérêt général. La désignation d'un exécuteur testamentaire est également nécessaire dans ce cas afin que la disposition soit effectivement appliquée sans difficulté.

2.7.7. Le testament

Les dernières dispositions du testateur doivent d'une manière ou d'une autre apparaître dans un document. Si rien n'existe, on passe au partage de l'héritage selon les règles légales. Mais comme beaucoup de testateurs désirent régler leurs dernières volontés d'une autre manière, ils doivent le faire dans un testament ou un pacte successoral. Les deux instruments présentent des avantages et des inconvénients. Dans le cas de problèmes complexes, il est recommandé d'examiner la succession avec un conseiller financier, un juriste ou un notaire afin de trouver la bonne solution.

2.7.8. Le testament olographe

Le testament olographe (de la main du testateur) constitue une forme de testament simple et largement répandue. Ce testament peut être établi par une personne sans l'intervention d'un notaire ; il doit donc être écrit à la main et comprendre le lieu et la date de sa rédaction. Si cette forme n'est pas respectée, il n'est pas valable et peut être attaqué en justice.

Le problème qui se pose aux héritiers avec le testament olographe est celui de savoir si l'exemplaire qu'ils ont en main est bien le dernier et donc celui qui est valable. C'est toujours le testament le plus récent qui est valable ! Il n'est pas obligatoire de déposer le testament auprès d'une autorité officielle (commune de domicile) mais cela constitue un avantage ; il est aussi possible de faire figurer le testament dans un registre centralisé. Le testament olographe contiendra de préférence les éléments suivants :

- renseignements sur le testateur (prénom et nom, date de naissance, lieu d'origine et adresse) ;
- révocation de testaments plus anciens ;
- institution d'héritier ;
- institution de legs ;
- indications de règles de partage ;
- désignation d'un exécuteur testamentaire ;
- lieu, date et signature.

Ce canevas est à recommander pour que le testament olographe soit compris des héritiers ou de l'exécuteur testamentaire et que les dernières volontés du testateur puissent

être exécutées. Les formulations qui laissent des possibilités d'interprétation ne doivent pas apparaître dans un testament car les conflits seront programmés d'avance.

2.7.9. Le testament notarié

Le testament notarié ou testament public est établi selon la loi cantonale par un notaire ou un autre officier public. Le testateur commence par confier ses dernières volontés au notaire. Cette conversation permet de répondre à des questions d'ordre juridique et de renforcer des convictions. Le notaire établit alors le testament et le donne à lire au testateur. Lorsque le testateur est satisfait de la formulation, on fait alors appel à deux témoins. Le testateur confirme en leur présence qu'il s'agit bien de ses dernières volontés.

Le testament entre en vigueur lorsque le testateur et le notaire ainsi que les deux témoins signent le testament. Les témoins n'ont pas connaissance du contenu du testament, par contre ils confirment que le testateur est capable de disposer pour cause de mort. Par rapport au testament olographe, le testament notarié présente l'avantage de supprimer les facteurs d'insécurité suivants :

- formulations peu claires ;
- conservation et sécurité ;
- connaissance du dernier testament et donc de celui qui est définitif.

Cette forme de testament est également choisie par des personnes qui sont en mesure de disposer elles-mêmes mais qui ne sont plus capables d'établir elles-mêmes leur testament.

2.7.10. Le testament d'urgence

Le testament d'urgence est celui qui est donné par oral en dernière extrémité, par exemple en cas d'accident, de maladie grave ou en cas de guerre. Un testament oral doit être donné en la présence d'au minimum deux personnes. Si la mort n'intervient pas dans les 14 jours, ce testament n'est pas valable. Les dispositions prises par le testateur en cas d'erreurs et de confusions ne sont pas valables. Il faut toutefois faire intervenir un tribunal. Dans le cas contraire, les dernières dispositions entrent en vigueur.

On comprend donc que ce type de testament constitue une solution qui peut poser de nombreux problèmes.

2.8. Le pacte successoral

Le pacte successoral permet également de contenir les dernières volontés du testateur, mais en plus il contiendra l'accord des futurs héritiers. On en arrive ainsi à l'accord de toutes les parties concernées. Le pacte successoral qui est établi par un notaire est signé par toutes les parties concernées (testateur et héritiers), en présence de deux témoins. Une modification du pacte successoral demande à nouveau la signature de

toutes les parties. Le testateur ne peut donc procéder à des modifications de son propre chef. Au contraire du testament, le pacte successoral est un outil moins flexible et plus lourd pour contenir les dispositions du testateur. En fait, le testateur ne peut modifier le pacte successoral qu'en cas de mauvaise conduite des héritiers ou d'un héritier ce qui peut conduire à une exhérédation. Le pacte successoral présente aussi quelques avantages à côté de ses inconvénients de lourdeur.

Au contraire du testament, les héritiers sont invités à participer aux opérations déjà du vivant du testateur. Cette approche permet de trouver des solutions en partenariat. On peut ainsi éviter les problèmes futurs entre héritiers et les patrimoines deviennent plus transparents. Comme le pacte successoral est établi par un notaire, il n'y a ainsi pas de risques qu'il soit contesté.

Il arrive souvent que le pacte successoral soit combiné avec un contrat de mariage. Cette manière d'aborder toutes les questions permet de bien planifier la succession mais le testateur doit bien comprendre les solutions car il sera ensuite très difficile de procéder à une modification. Le pacte successoral permet de prendre les mêmes dispositions que le testament, c'est-à-dire l'institution d'héritier et de legs, etc. Il est possible de procéder en plus à des renoncations d'héritage qui peuvent être compensées par des versements, si possible à la signature du contrat. Une renonciation peut également être réglée dans un contrat séparé. Il ne faut alors régler dans le pacte successoral que la partie qui concerne la réserve, il en va de même du testament qui réglera la quotité disponible.

La renonciation d'héritage sera utile lorsque des biens difficilement partageables doivent être répartis entre plusieurs héritiers.

Exemple :

Monsieur Durand a investi presque tout son patrimoine dans sa propre entreprise. Il est marié et père de trois enfants. Sa fille travaille déjà depuis deux ans dans l'entreprise et doit lui succéder. Les parties conviennent d'un pacte successoral dans lequel il est convenu que l'entreprise soit attribuée à la fille. L'avoir en espèces est remis aux deux autres enfants qui acceptent de renoncer au solde de l'héritage. Si d'autres espèces devaient être disponibles au décès de Monsieur Durand, elles seraient remises à son épouse. Ces volontés sont réglées par un pacte successoral, y compris les renoncations d'héritage et les compensations.

La renonciation d'héritage peut aussi être intéressante dans des cas particuliers. Par exemple, dans le cas de concubins (les parents renoncent à l'héritage en faveur du concubin survivant) ou dans le cas où un testateur laisserait un enfant handicapé. Dans ce dernier cas, un tuteur ou le conjoint survivant peuvent s'occuper de l'enfant à l'aide des fonds mis à leur disposition.

2.9. Réalisation des dernières volontés

2.9.1. La dévolution

La dévolution s'intéresse à la transmission des biens à la mort du défunt. Les héritiers bénéficient à ce moment des droits et des devoirs du défunt sur la masse successorale. Les dettes en font également partie. L'ouverture de la succession sur l'ensemble des biens s'effectue au dernier domicile. Comme les héritiers prennent certains risques, ils peuvent donc aussi répudier la succession, bénéficier d'un inventaire ou demander la liquidation officielle.

2.9.2. La répudiation de la succession

Dans le cas d'une succession qui est trop endettée, les héritiers (légaux et institués) vont répudier leur succession. C'est une démarche qui doit être entreprise par les héritiers dans les 90 jours, sinon la succession est acceptée. La répudiation doit être entreprise auprès de l'autorité cantonale compétente. Il est préférable de le faire par écrit. Les créanciers pourront agir contre les héritiers et les poursuivre si une succession trop endettée est acceptée par ces mêmes héritiers.

2.9.3. Le bénéfice d'inventaire

La situation du patrimoine du défunt n'est pas toujours claire. Il est conseillé de faire établir un inventaire dans le cas d'un endettement trop élevé de la succession. Cet inventaire peut être demandé auprès de l'autorité cantonale compétente dans les 30 jours.

Les autorités procéderont à un appel aux créanciers. Cette procédure permettra de faire apparaître la situation exacte du patrimoine du défunt. Les héritiers pourront alors prendre une décision en connaissance de cause après l'établissement de l'inventaire officiel, ils pourront choisir parmi les solutions suivantes :

- répudier la succession à cause de son endettement ;
- accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ;
- demander la liquidation officielle.

2.9.4. La liquidation officielle

Lorsque dans le cas d'un héritage on se trouve dans une situation d'incertitude où on ne sait pas si la succession est trop endettée ou pas, il est alors possible de demander la liquidation officielle à la place du bénéfice d'inventaire. La liquidation officielle est dans la plupart des cantons effectuée par un notaire. Les héritiers ne sont pas responsables de la succession dans le cas d'un endettement excessif.

2.9.5. Ouverture du testament

Le testament trouvé après le décès doit être remis aux autorités cantonales compétentes. Il est de ce fait certainement avantageux d'annoncer les testaments existants à un registre central. Les testaments peuvent être déposés auprès des offices cantonaux ou auprès des notaires. Il est important qu'un nouveau testament soit également déposé car sinon on peut créer un doute sur son authenticité. Les pactes successoraux ne doivent être déposés que si cela a été prévu dans le pacte.

2.10. Le partage de la succession

La mort du testateur fait passer la propriété de son patrimoine aux héritiers. Dans le cas où il y a plusieurs héritiers, ils forment une communauté héréditaire.

2.10.1. La communauté héréditaire (hoirie)

Les héritiers sont propriétaires en commun de l'héritage. Tous les actifs leur appartiennent en commun. Ils sont également solidairement responsables des dettes. Cela signifie que ce n'est pas seulement le patrimoine héréditaire qui répond des dettes mais aussi le patrimoine personnel de chaque héritier.

Lorsque rien d'autre n'a été convenu, la communauté héréditaire doit effectuer en commun tous les travaux d'ordres administratifs et juridiques (p. ex. relations avec les banques). Le partage de la communauté héréditaire peut être demandé par un des héritiers dans la mesure où il n'y a pas de prescriptions légales ou contractuelles qui s'y opposent. En principe, c'est la communauté héréditaire qui doit procéder au partage. Mais comme cela peut conduire à des différends, il est utile de faire intervenir un exécuteur testamentaire, surtout dans le cas d'une répartition complexe du patrimoine. Certains cantons connaissent des offices de médiation qui peuvent prendre à leur compte la fonction d'exécuteur testamentaire lors du partage de la succession.

Lorsque les héritiers ne peuvent pas se mettre d'accord lors du partage de la succession, ils peuvent former des lots. Cela peut aussi être demandé par l'autorité compétente. L'attribution des lots s'effectue selon le libre accord des parties ou par un tirage au sort. Le partage peut être effectué très rapidement en présence de valeurs mobilières. On peut rencontrer des problèmes d'évaluation (p. ex. cours des papiers valeurs au jour du décès). Le partage d'immeubles est plus difficile, il en va de même des entreprises. La communauté héréditaire peut aussi subsister sur une durée plus longue, en particulier lors d'héritages d'immeubles. Les immeubles sont évalués pour le partage à leur valeur vénale. Il y a des règles particulières pour les exploitations agricoles.

Exemple :

Madame Durand décède et laisse trois enfants majeurs. La succession se compose principalement d'un immeuble locatif entièrement loué. Comme les héritiers ne peuvent pas se mettre d'accord sur le partage, ils conviennent de prolonger la communauté héréditaire qui va gérer l'immeuble pendant plusieurs années.

2.10.2. Le légataire

Un légataire ne fait pas partie de la communauté héréditaire. Il reçoit un objet déterminé ou une somme d'argent mentionnée dans le testament. Comme le légataire ne devient pas automatiquement propriétaire, il doit faire valoir son droit auprès de la communauté héréditaire ou de l'exécuteur testamentaire.

2.10.3. Le conjoint survivant

Le conjoint survivant est bien un héritier légal. Mais il ne bénéficie pas de cette position lorsqu'il reçoit une usufruit sur le patrimoine de la succession à la place de sa part héréditaire sans avoir été institué héritier pour la quotité disponible. Il est dans ce cas uniquement bénéficiaire de l'usufruit.

Il doit également faire valoir aux héritiers sa part de liquidation du régime matrimonial que ce soit du régime légal ou en vertu d'un contrat de mariage.

2.10.4. La clôture du partage

La clôture du partage est exécutée lorsque les étapes suivantes ont été accomplies :

- décompte et attribution des lots ;
- signature d'un contrat écrit de partage.

Il est important de payer les dettes et les impôts de succession avant de terminer le partage. Il est aussi possible de prévoir une réserve à cet effet. Les héritiers demeurent encore solidairement responsables pendant 5 ans.

2.10.5. Actions en justice

Dans le cas où des héritiers se sentiraient injustement traités, ils ont la possibilité de faire valoir leurs droits. Dans un premier temps, il est toujours utile de commencer par chercher une solution avec les personnes concernées et de trouver un accord à l'amiable. Mais si l'objectif voulu n'a pas été atteint, il est possible de procéder en justice :

- action en réduction lorsque les parts n'ont pas été respectées, dans un délai d'un an dès la connaissance de la lésion ;
- action en nullité de forme en présence d'un testament, dans un délai d'un an dès la connaissance du testament et du motif de non-validité ;
- action de l'héritier sur des éléments de la succession qui sont en possession d'un tiers, également dans un délai d'un an dès la connaissance de la possession et de son propre droit ;
- action en partage ou en renvoi du partage après la mort du testateur (p. ex. renvoi du partage qui entraînerait une perte importante en cas de vente).

2.11. Mesures en cas de décès

Chaque décès entraîne la prise d'un inventaire par l'autorité cantonale. Les héritiers et éventuellement l'exécuteur testamentaire sont tenus de fournir toutes les données et documents, les relevés bancaires ainsi que le logement. Pour des motifs de sécurité, les autorités cantonales peuvent également apposer des scellés ce qui favorise les héritiers absents. L'autorité cantonale de tutelle est informée en présence d'héritiers mineurs.

Testaments	Ils doivent être remis à l'autorité compétente même lorsqu'ils ne sont plus valables.
Assurances-vie	Le décès doit être communiqué à la société d'assurance avec l'avis de décès. Les prestations d'assurance sont versées aux bénéficiaires indépendamment du fait qu'ils soient héritiers ou non. Ces versements sont effectués immédiatement et indépendamment du partage.
Attestation d'héritier	Les attestations d'héritier mentionnent les héritiers légaux et institués. Elles servent de preuve du droit à la succession et sont établies dès que les héritiers sont connus.
Procurations bancaires	Les procurations bancaires sont en règle générale valables après la mort du titulaire du compte. Mais les héritiers peuvent annuler ces procurations et disposer en commun des comptes sur présentation des attestations d'héritiers.
Documents	Que ce soit pour le partage de la succession ou pour les déclarations fiscales, il est nécessaire de disposer des documents complets sur tous les actifs et passifs au jour du décès (hypothèques, papiers-valeurs, etc.).

3. Planification optimale de la succession

3. Planification optimale de la succession

On ne répétera jamais assez qu'il y a d'excellentes raisons d'entreprendre une planification de sa succession suffisamment tôt. Cette planification représente cependant un sujet tabou dans beaucoup de familles suisses. Cette approche doit être prise en compte par le conseiller financier car les avantages attendus d'une telle planification ne sont pas toujours évidents. Il faut en effet considérer que les éléments rationnels ne sont pas toujours décisifs et qu'il faut aussi tenir compte d'éléments émotionnels dont voici quelques exemples :

- une réflexion sur sa propre mort n'est pas évidente ;
- cette approche peut encore attendre et ne doit pas être entreprise aujourd'hui ;
- les enfants doivent gérer eux-mêmes leur existence ; etc.

Les motifs peuvent être nombreux et ils constituent souvent un frein à la mise en place de solutions optimales. Une planification entreprise suffisamment tôt permet toutefois de trouver une bonne solution pour toutes les personnes concernées et de tenir compte des différents désirs. L'ancienne génération n'a souvent plus besoin de la totalité de son patrimoine par contre la nouvelle génération pourrait faire bon usage de certains éléments de fortune pour l'achat d'une maison ou la création d'une entreprise.

Enfin, une transmission anticipée de patrimoine peut générer des effets positifs. Les donations liées à la jouissance d'usufruit peuvent entraîner des économies d'impôt. La transmission anticipée de la fortune peut dans certains cas protéger la fortune d'une intervention étatique ; il faudra également tenir compte de cet aspect dans l'analyse de la situation (p. ex. le libre choix du lieu de séjour dans une institution de retraite).

Nous présentons dans la suite de ce chapitre différentes approches de planification qui peuvent en règle générale être combinées avec d'autres mesures afin d'arriver à une solution optimale.

3.1. Donations et avances sur héritage

Une personne peut de son vivant disposer librement de sa fortune. Des limitations peuvent intervenir dans le cas de personnes mariées. Une personne a toutefois la possibilité de procéder à des donations à d'autres personnes ou à des institutions. Ces donations sont soumises à un impôt sur les donations.

Il y a beaucoup de raisons qui permettent d'envisager une donation. La plupart des donations interviennent toutefois dans le cadre de la famille. Il faut cependant prendre en considération certaines limitations car ces donations entraînent des transmissions de patrimoine à de futurs héritiers. Une aide de départ à la création d'une entreprise ou à l'achat d'une maison constituent souvent des motifs de donation. Celle-ci peut également être envisagée pour la succession dans le cadre d'une entreprise.

Contrairement à la donation en faveur de tiers, les donations en faveur d'héritiers légaux constituent une avance d'héritage. Ces éléments n'apparaissent plus dans la future succession. Celui qui a reçu un élément de fortune sur le compte d'un droit futur d'héritier doit compenser cette avance. Les héritiers doivent procéder à cette compensation dans la mesure où cela a été prévu d'avance ou dans le cas où les droits d'autres héritiers ont été lésés. Certains héritiers peuvent être libérés de la compensation (p. ex. par testament) mais la protection des autres héritiers doit être garantie. Dans le cas contraire, les autres héritiers peuvent obtenir la compensation de leurs droits par voie de procédure judiciaire. On compense en règle générale la valeur de l'objet à la date du décès. On peut cependant conseiller de fixer déjà la valeur de la compensation au moment de la donation afin d'éviter des situations difficiles. Il faut également tenir compte de l'existence éventuelle d'une plus-value qui doit être compensée dans le cas où rien d'autre n'a été convenu.

3.2. Compensation d'héritage

Il est également possible de transmettre des éléments de patrimoine à un héritier de son vivant. L'héritier renonce alors à sa part équivalente future d'héritage. Cet héritier reçoit ainsi une compensation de sa renonciation future en faveur des autres héritiers.

3.3. Prêt

Il peut arriver dans un cadre familial que l'ancienne génération désire favoriser la nouvelle tout en ne désirant pas abandonner la propriété de la fortune (donation). L'octroi de prêts sans intérêt constitue une solution idéale à cet effet. Cette solution permet aux héritiers de réaliser immédiatement leurs acquisitions sans avoir à supporter une charge d'intérêts. Les sommes prêtées peuvent tout de même être récupérées par l'ancienne génération dans le cas de modifications des rapports familiaux.

Il est utile de préciser les modalités de prêt dans un contrat. Cette forme de transmission de fortune est souvent utilisée pour l'achat d'une maison ou la création d'une entreprise. Un prêt n'est pas soumis à l'impôt sur les donations contrairement aux autres formes de transfert de patrimoines décrites ci-dessus.

3.4. Donation mixte

La donation mixte peut être utilisée lorsqu'une partie du transfert de patrimoine s'effectue contre le versement d'une prestation financière. Il est par exemple possible de transférer une maison familiale à un héritier en payant une partie de sa valeur. Cette solution est utile lorsqu'il s'agit d'indemniser les autres héritiers.

Exemple :

Monsieur et Madame Martin ont deux enfants. Ils font donation de leur maison de vacances en Valais à l'un des deux enfants. La valeur commerciale s'élève à CHF 350'000.– et il y a une hypothèque de CHF 50'000.–. Un des enfants reprend le bien immobilier et paie un prix d'acquisition de CHF 150'000.–. Il bénéficie ainsi d'une donation de CHF 150'000.–. Après avoir reçu cette somme, les époux remettent en donation le montant de CHF 150'000.– au second enfant.

Sur le plan fiscal, il y aurait également une donation mixte si les parents avaient augmenté l'hypothèque de CHF 150'000.– peu avant le transfert immobilier. Il faut également tenir compte, dans ces opérations, de l'impôt sur les gains immobiliers et des droits de mutation.

3.5. Usufruit et droit d'habitation

L'usufruit ou le droit d'habitation constituent des droits intéressants dans le cas de la propriété d'un bien immobilier. Un usufruit fonctionne de la manière suivante :

Le donataire est bien le propriétaire des biens mais il n'en reçoit pas les produits. L'usufruitier bénéficie de tous les revenus de ce patrimoine ; mais il doit aussi en supporter les charges correspondantes. Dans le cas de biens immobiliers, il s'agit des frais d'entretien et de réparation et pour un portefeuille de titres des frais de gestion. L'usufruitier supporte en règle générale également les impôts sur le revenu et la fortune.

Un usufruit peut être limité dans le temps ou durer une vie entière. L'usufruitier n'exerce pas de droit sur le bien. Il ne peut donc pas vendre un bien immobilier. De même, un capital ne peut pas être vendu par un usufruitier. Ce système offre l'avantage de placer le bien déjà en mains du nouveau propriétaire alors que les revenus sont versés pour l'entretien d'une autre personne. La différence entre le droit d'habitation et l'usufruit se trouve dans le fait que le droit d'habitation permet à une personne d'habiter un appartement ou une maison sans qu'il y ait de prestations financières (p. ex. revenus de la location d'un appartement sous-loué).

L'usufruit et le droit d'habitation sont souvent utilisés dans le cadre familial dans la planification de la succession. Des immeubles sont ainsi souvent transférés du vivant de leur propriétaire et les parents conservent l'usufruit à vie (jusqu'au décès du second con-

joint). Ce système est également choisi pour des raisons fiscales car un usufruit ou un droit d'habitation est capitalisé pour être déduit du montant déterminant imposé dans le cadre de la donation.

3.5.1. Utilisation du soutien de famille

Beaucoup de personnes âgées craignent que leur épargne accumulée pendant des années soit totalement utilisée par un séjour dans une institution pour personnes âgées et qu'il ne reste plus rien pour les descendants. Cette crainte est certainement justifiée compte tenu des frais élevés qui peuvent se monter à plusieurs milliers de francs par mois, voire jusqu'à CHF 10'000.–.

Beaucoup de personnes organisent leur planification successorale en fonction de ces coûts. Il faut toutefois tenir compte du fait que la transmission de patrimoine du vivant des parents peut conduire à une situation où ceux-ci ne disposent de pratiquement plus de fortune ou de revenus. Les parents ne peuvent alors même plus décider dans quelle institution ils doivent être accueillis. Dans ce cas, c'est l'Etat qui détermine le lieu et paie les frais nécessaires. Mais compte tenu de la situation financière des pouvoirs publics, ceux-ci prélèvent directement les frais sur les revenus des héritiers. La base juridique se trouve dans le code civil à l'art. 328 qui prévoit que les parents doivent être entretenus financièrement par la famille en ligne ascendante et descendante.

La Conférence suisse en matière d'aide sociale donne par ailleurs des directives sur le financement de l'Etat par l'intermédiaire des familles. Ces directives sont complétées ou remplacées par des prescriptions cantonales. Elles se basent sur le revenu et la fortune fiscale des héritiers. Des situations sensibles se présentent surtout lorsque parmi les membres de la famille des donations sont intervenues ; en particulier quand ces donations interviennent peu avant l'entrée en maison de retraite. Les autorités partent alors du principe qu'il ne s'agit que d'une protection de patrimoine.

L'application de ces directives varie beaucoup d'un canton à l'autre. Dans la plupart des cantons, l'aide sociale incombe aux communes. Des prétentions seront présentées aux héritiers en fonction de la taille de la commune. Un procès sera intenté dans le cas où les héritiers refusent de prendre cette charge à leur compte et cette situation provoque des frais qui ne peuvent être pris en compte que par les grandes communes.

Il peut donc s'avérer utile de transférer suffisamment tôt un patrimoine à la génération suivante compte tenu de cet aspect de protection du patrimoine. Une bonne planification devrait également tenir compte des désirs de l'ancienne génération pour ce qui est du choix de la maison de retraite. Beaucoup d'institutions privées sont plus avantageuses pour les particuliers fortunés que les institutions d'état. Les maisons de retraite d'état appliquent un tarif en fonction de la fortune d'une personne alors que les institutions privées appliquent un tarif général. Il peut donc être intéressant de transférer un patrimoine du vivant des parents. Mais un revenu élevé (provenant par exemple d'un usufruit) devrait permettre le libre choix d'une institution.

3.6. Mesures de protection du conjoint

Ces mesures visent en premier lieu à accorder au conjoint survivant le même niveau de vie que précédemment. Cet objectif est souvent impossible à atteindre sans mesures concrètes car une partie substantielle du patrimoine passe à d'autres héritiers. Le conjoint survivant subit dans tous les cas des restrictions de revenus et une modification des anciennes habitudes dans son standard de vie.

Une meilleure protection du patrimoine du conjoint survivant peut être obtenue par les mesures suivantes :

- règlement par un bon choix du régime matrimonial applicable au conjoint survivant ;
- règlement par des dispositions testamentaires adaptées ;
- couverture supplémentaire par une police d'assurance-vie liée à d'autres mesures de prévoyance de l'Etat ou d'une caisse de pensions.

La protection du conjoint survivant commence avec le choix du régime matrimonial. Il est déjà possible d'utiliser à ce niveau des mesures de protection du conjoint survivant. Les possibilités ont été indiquées dans le chapitre consacré aux régimes matrimoniaux. Du point de vue du droit successoral, il est possible de prendre trois mesures :

- la quotité disponible est attribuée au conjoint survivant en plus de la part réservataire ;
- le conjoint survivant bénéficie de l'usufruit à vie sur tout le patrimoine matrimonial (n'est possible qu'à l'égard de ses propres enfants) ;
- les enfants ou les parents du défunt renoncent à l'héritage en faveur de leur mère.

Des formules mixtes sont également possibles. Ainsi le conjoint survivant peut également en plus de sa part réservée recevoir la quotité disponible et bénéficier de l'usufruit sur le solde de l'héritage.

De même, l'utilisation de règles de partage permettent au conjoint survivant de bénéficier du droit de conserver la propriété de certains objets de son choix. Le résumé suivant met en évidence les possibilités qui s'offrent aux époux qui disposent d'un patrimoine commun :

Le conjoint survivant reçoit dans le cas d'un patrimoine commun				
En droit matrimonial	En droit des successions			
Propriété en plus de la 1/2 du bénéfice ou selon contrat de mariage	De la succession	Part légale	Quotité disponible en propriété	Usufruit
	Sans dispositions	1/2		
	Supplément	1/2	1/8	
	Usufruit		1/8	7/8

La variante de la renonciation à l'héritage constitue un instrument idéal dans le cadre de couples sans enfant afin de «contourner» les parents. Ces derniers signent une renonciation à l'héritage en faveur du conjoint survivant sinon ils disposeraient d'une part en l'absence de cette formalité.

Cette solution peut aussi être appliquée dans le cas de couples qui n'ont pas d'enfants en commun.

Des sécurités supplémentaires peuvent être prises en cas de décès au moyen de polices d'assurance sur la vie. Il est cependant toujours recommandé de commencer par régler les aspects du régime matrimonial et du droit des successions avant de conclure des polices d'assurance sur la vie. On économise ainsi des frais inutiles et on évite une sur-assurance. Les couples sans enfant et qui n'ont plus de parents peuvent sans problème instaurer le conjoint survivant comme héritier universel à l'aide d'un testament ou d'un pacte successoral. Le conjoint survivant dispose du droit légal de continuer à disposer du domicile conjugal ainsi que du mobilier de ménage. Cette disposition est automatiquement appliquée si aucune disposition particulière n'a été prise au préalable.

3.7. Planification de la succession dans le cas de partenariats assimilables au mariage

Le règlement de la succession est très important dans le cas de partenariats assimilables au mariage (concubinage). Le partenaire survivant ne dispose d'aucun droit du point de vue légal. Il n'est ni héritier légal, ni protégé par une part réservataire. Dans le cas de la planification successorale, il est particulièrement important de définir qui sont les héritiers légaux et qui est réservataire. Il est alors possible dans le cadre des personnes concernées (p. ex. les parents) de procéder à une planification de la succession.

L'ensemble du patrimoine du défunt passe à la succession. Il peut tout d'abord être très important de pouvoir définir quels sont les biens du ménage qui appartenaient au défunt. Il n'y a dans ce cas pas d'acquisitions communes ou de régime particulier. De ce fait, tous les biens qui ont été acquis par les revenus courants font partie de la succession. Sans dispositions testamentaires du défunt, le partenaire survivant ne pourra pas bénéficier d'un héritage. Les possibilités suivantes permettent toutefois au partenaire survivant d'être bien couvert :

- le partenaire est institué comme héritier et il reçoit tout ou partie de la quotité disponible ;
- établir des procurations ;
- renonciation des héritiers réservataires en faveur du conjoint survivant ;
- procéder à des donations de son vivant ;
- utiliser les possibilités de l'assurance-vie pour financer des moyens supplémentaires.

La plupart des manifestations de volonté peuvent être englobées dans un testament olographe. La renonciation à la succession des parents ou d'un descendant (enfants communs ou non communs) doit toutefois être réglée dans un contrat devant notaire.

Exemple :

Madame Martin vit avec Madame Reymond depuis 15 ans dans un appartement commun. Elle désire assurer la situation de Madame Reymond de manière optimale dans le cas d'un décès prématuré. Comme sa mère vit encore (héritier réservataire), elle demande une renonciation à l'héritage. La mère donne son accord et signe le contrat. De plus, Madame Martin stipule dans un testament olographe qu'elle cède toute la quotité disponible à Madame Reymond. Celle-ci devient donc héritière unique.

Dans le cas d'une mauvaise entente familiale, il est utile de conclure un pacte successoral ou de faire établir un testament notarié afin d'éviter des conflits futurs.